

1501628-51.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343385/2021 - DEL.POL.PLANTÃO

TATUI, 22002497 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2998/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI,

2343385 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

KAIQUE ALEXANDRE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501628-51.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343385/2021 - DEL.POL.PLANTÃO

TATUI, 22002497 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2998/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI,

2343385 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

KAIQUE ALEXANDRE TAVARES MARTINS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP c/c Art. 40

"caput", III do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

15/08/2022

Em 15 de agosto de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: a representante do Ministério Público, na pessoa da DR.^a FABIANA MARIA NOVAES CANATELLI RODRIGUES, DD^a. Promotora de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu KAIQUE ALEXANDRE TAVARES MARTINS, bem como sua Defensora Técnica, DRA. Sabrina de Moraes Torres OAB 358503/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Sandro Martins Camargo (GM) e Luis Adriano Nogueira (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com a sua Defensora. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao

interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MMª Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu KAIQUE ALEXANDRE TAVARES MARTINS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, eis que, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 20h02, na rua Isaltino Campos Vieira, nº 261, Vila Angélica, nesta cidade e Comarca de Tatuí, trazia consigo, guardava e ocultava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 19 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 17,32 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta da exordial, na data mencionada acima, praticava tráfico de drogas, nas proximidades do "Bar do Gordo", fazendo entrega aos usuários que o procuravam. Para tanto, KAIQUE guardava porções de droga no interior de cano de esgoto, rente à calçada, de forma a dificultar a apreensão. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina quando receberam informação de que o acusado estava praticando o comércio ilegal, sendo descritas suas vestes e, também, o local onde ocultava os entorpecentes. Os agentes públicos se dirigiram ao endereço e avistaram KAIQUE abaixado rente à calçada, o qual, ao notar aproximação da viatura, levantou-se e seguiu em direção ao bar. Houve a abordagem. Em revista pessoal, com o denunciado foram encontrados R\$ 141,00 e, entre as notas, 02 porções de cocaína. Dando continuidade às diligências, os Guardas localizaram 17 porções de cocaína no local em que KAIQUE foi avistado, as quais estavam embaladas de forma idênticas às anteriormente apreendidas. O réu foi notificado (fls. 110) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 116/117). Assim, por decisão proferida no dia 27 de julho de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 121/122). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do réu nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, por outro lado, pugnou pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, pela aplicação de todos os benefícios legais cabíveis a incidir em fase de dosimetria da pena e da fixação do regime prisional inicial. Certidões a fls. 28/29 e 139/140. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido acusatório comporta parcial procedência. De fato, deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pelas razões que passo a expor. A despeito da majorante em questão ter natureza objetiva e, portanto, dispensar a intenção do traficante de captar sua clientela junto aos frequentadores dos locais elencados no dispositivo legal supra citado, tem-se que, para não gerar responsabilidade penal objetiva, exige-se que haja concentração de pessoas nas proximidades e adjacências daquele lugar para justificar a incidência da causa de aumento especial em tela. Ora, a ratio da norma visa exasperar a pena de pessoa que se aproveita da aglomeração de pessoas nas proximidades daquele local, facilitando a ocultação e evasão do traficante. In casu, como os fatos se deram em dezembro e o estabelecimento de ensino apontado a fls. 76 está em férias e, sem funcionamento portanto, naquela época. Ou seja, estava fechado na data dos fatos, não havendo concentração de pessoas a justificar a incidência da causa de aumento em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. INFRAÇÃO

COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM UMA MADRUGADA DE DOMINGO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE UMA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. 2. A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância.

3. Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018). No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/112), pelo auto de constatação preliminar (fls. 13/14), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 72/75) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente incontestada. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 05), afirmou que, na data dos fatos, não estava vendendo drogas no local e que estava lá, Bar do Gordo, ingerindo bebidas alcoólicas e usando cocaína. No entanto, em nenhum momento estava comercializando drogas. Faz uso de entorpecente há seis anos. Alegou que comprou a droga no mesmo endereço em que foi detido de um desconhecido. Em juízo, disse que no dia dos fatos estava com uma camiseta preta do time da Vila Angelica e havia outras pessoas com a mesma camiseta no local, pois é uniforme do time e ocorria uma festinha que comemorava um jogo. Estava para dentro do balcão do bar, junto do proprietário que é o gordo, os GCM adentraram ao local, ele estava com duas porções, sendo que uma estava pela metade, pois estava usando. Estava no local errado, com pessoas erradas. Estava para dentro do balcão do bar, em hipótese alguma estava do lado de fora. Comprou as porções em frente ao bar e não sabe o nome da pessoa. Todos do time estavam dentro do bar. Varias pessoas foram abordadas, só que somente ele estava com uma porção intacta, a dos outros já estava deflagrada. Não viu quando os GCMs encontraram as porções. Não tem nada contra os guardas, eles fazem o trabalho deles. Tem 24 anos. E ajudante de pintor, tem filhos, é amigado. Tem um artigo 28. Foi condenado recentemente num tráfico. Foi atribuída a ele nesse processo, crack, maconha e cocaína, mas só o pó era dele. O dinheiro havia recebido há 3 dias do seu patrão Luan. Analisando a autodefesa do acusado – colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa –, resta evidente que o acusado assumiu a posse das drogas encontradas em seu poder, mas negou as posse das demais porções, bem como a destinação comercial. Contudo, a negativa de finalidade mercantil da droga restou inverossímil, pois desprovida de lastro argumentativo lógico, e foi afastada pela prova produzida nos autos. Há que se observar que o réu encontra-se preso por outro processo, sendo que fora condenado por sentença recorrível pelo crime de tráfico de entorpecentes. De fato, o Guarda Civil Municipal Luis Adriano Nogueira, em sede policial (fls. 03), declarou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, realizavam patrulhamento, momento em que receberam uma “denúncia” de um transeunte. O denunciante informou que no local, Bar do Gordo, um indivíduo, o qual trajava camiseta preta e bermuda, estava escondendo drogas no “cano de esgoto” próximo ao referido bar. Assim, se deslocaram até o local indicado e, lá, constataram o

suspeito, abaixado, próximo ao meio fio da calçada, o qual ao avistar a presença da viatura, levantou rapidamente, caminhou e adentrou no bar. Abordaram o suspeito na frente do bar, sendo tal indivíduo identificado como KAIQUE ALEXANDRE TAVARES MARTINS. Em revista pessoal, localizaram com ele a importância de R\$ 141,00 e, no meio deste dinheiro, tinha duas porções de cocaína do tipo aricanduva. Relatou que foram averiguar o local indicado na denúncia, onde KAIQUE se encontrava anteriormente, onde foram localizadas mais 17 (dezesete) porções de cocaína, idênticas às encontradas com o indiciado durante revista pessoal. Indagado, o réu negou a traficância.. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Angelica, quando uma pessoa os abordou e disse que próximo ao bar do gordo, um rapaz tirava algo de um cano e depois vendia a droga no bar. Foram ao local, viram um indivíduo abaixado na calçada, ele levantou rapidamente e adentrou ao bar. No local que ele estava abaixado foram encontradas 17 porções idênticas as encontradas com o réu. Com no réu foram encontradas duas porções de cocaína e o valor de R\$141,00. O réu negou a venda e a propriedade das 17 porções. Não aparentava estar sob efeito de substância entorpecente. Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Sandro Martins Carmargo, em solo policial (fls. 04), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, disse que estavam num bairro Jardim Aeroporto que fica em frente a Vila Angelica e que havia um indivíduo no local fazendo a venda de entorpecentes no bar do gordo e tirava a droga num cano de esgoto. Foram o local apontado, viram o réu abaixado na calçada e ele ao avistar a viatura adentrou ao bar. Com ele foram encontradas 2 porções de cocaína e dinheiro. No local em que ele estava abaixado, dentro de um pote foram encontradas mais 17 porções idênticas as que estavam em poder do réu. O réu negou o tráfico e não aparentava estar sob efeito de substância entorpecente. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos adotados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos guardas, os quais narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas com o acusado e o restante onde foi visto, antes da abordagem, abaixado; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 72/75), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito

previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; 4) o comportamento suspeito apresentado pelo acusado, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se rapidamente e tentou ingressar no bar, para não ser abordado; e 5) a exata correspondência entre as vestes do réu, além das demais circunstâncias fáticas, com a do traficante delatado anonimamente. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642,

776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 72/75) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 - trazer consigo e guardar -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. De fato, observo que os apontamentos criminais retratados a fls. 28/29 e 139/140 se referem a ações penais em curso e, a despeito de entendimento pessoal diverso dessa Magistrada, observo que a jurisprudência se consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a valoração negativa em primeira fase (Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisórias: "embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça." (TJSP; Apelação Criminal 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). Desse modo fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante à minguagem de outras causas modificadoras da pena a incidir. Cabe ressaltar que não foi aplicada a atenuante de confissão, pois o acusado limitou-se a admitir a posse de parte das drogas, alegando destinação para uso próprio. E isso expressa confissão de crime diverso do qual é condenado, motivo pela qual não se presta a caracterizar a atenuante de confissão (Súmula nº 630 do C. STJ). E mais, não foi aplicada agravante do estado de calamidade pública. Isso porque não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de réu que está sendo processado em outros feitos (fls. 28/29 e 139/140), inclusive ostenta condenações provisórias por ilícitos tipificados na Lei de Drogas, elemento caracterizador de dedicação a atividades criminosas e que, por consequência, inviabiliza a concessão da benesse em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: "É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, §

4º, da Lei n.º 11.343/2006." (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime fechado, considerando a personalidade incorrigivelmente criminoso do acusado. Aliás, convém aprofundar que o acusado, mesmo em liberdade provisória concedida nesses autos, o acusado tornou a ser envolver com a criminalidade (fls. 139/140), denotando franca escalada delitiva, a qual somente pode ser contida pela fixação do regime prisional mais severo (art. 33, § 3º, c.c. art. 59, inciso III, ambos do Código Penal). Ademais, observo que as circunstâncias que justificaram a fixação do regime prisional mais severo também impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A tão só quantidade de pena inviabiliza a concessão do sursis. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para, afastando a causa de aumento de que trata o art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, condenar o réu KAIQUE ALEXANDRE TAVARES MARTINS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Defiro o Apelo em Liberdade ao réu, observando-se que se acha preso por outro feito. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 132) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 141,00 em dinheiro - fls. 111) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminoso. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei". Pela Defensora do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo a Defensora, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 112). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA